

1501687-28.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... do réu com relação ao crime de tráfico. (TJSP, Apelação Criminal n.º 0001970-74.2016.8.26.0616, 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda, julgado em 14/08/2020)

Apelação - Tráfico de entorpecentes, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores - Recurso da defesa - Absolvição por insuficiência de provas -

Materialidade e autoria do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501687-28.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501687-28.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251783/2022 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 27428698 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2251783 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DE SOUZA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

THIAGO DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 70, caput, do CP.

Isso porque, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 13h40min, na Rua Soldado-Polícia Militar Gilberto Augustinho, n.º 109, Valo Velho, nesta cidade e Comarca de Itapecerica da Serra, o réu, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Vinícius Carvalho de Oliveira, trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu corrompeu o adolescente Vinícius Carvalho de Oliveira, com ele praticando o crime descrito.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (f. 94-95).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 29 de setembro de 2022 (f. 60-61).

O réu foi citado, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 123-124). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 125-126).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática das infrações penais previstas nos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90, ambos na forma do art. 70, caput, do CP.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

De início, tem-se que o caso em tela reclama a aplicação do instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP), porquanto a descrição fática contida na denúncia melhor se amolda ao art. 33, caput, combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei n.º

11.343/06 – e não ao art. 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90 (ECA), como apontado pelo Parquet.

A respeito da possibilidade de realização da emendatio libelli diretamente na sentença sem a necessidade de prévia oitiva das partes, é oportuna a lição de Nestor Távora e Rosmar Alencar:

Neste caso, a denúncia ou a queixa já contém toda a descrição fática do crime que o juiz está a reconhecer na sentença, havendo simples equívoco na indicação do tipo penal pelo Parquet, ou pelo querelante. Não há, pois, óbice a que o juiz proceda à correção (emendatio libelli) e sentencie de plano, sem necessidade de oitiva prévia das partes, ainda que o dispositivo legal estabeleça pena mais grave. Como o réu se defende dos fatos e não da mera tipificação legal, não há que se falar em prejuízo.

No mesmo sentido, é o escólio de Renato Brasileiro:

Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte, em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença não leva em consideração o pedido formulado pela parte acusadora, já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa, comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade delituosa. (...) Por força dela [emendatio libelli], o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja aplicação de pena mais grave. (...) é majoritário o entendimento no sentido de que, na emendatio libelli, não há necessidade de se abrir vista às partes para que possam se manifestar acerca da nova classificação do fato delituoso. A justificativa para tanto é a de que, em sede processual penal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação (princípio da consubstanciação). Assim, como não há alteração da imputação na emendatio libelli, mas mera correção de classificação mal formulada, acusado e defensor já teriam tido a oportunidade de oferecer resistência à pretensão acusatória.

Pois bem, quanto à adequada capitulação dos fatos descritos na denúncia, tem-se que, no caso concreto, o crime de tráfico foi praticado com o envolvimento de adolescente, o que configura a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06, que assim aduz, in verbis: “As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;”.

No caso, como há norma específica prevista em legislação especial, incide na espécie o princípio da especialidade, a fim de afastar a norma geral (crime de corrupção de menores previsto no ECA) para aplicação da norma especial (causa de aumento prevista na Lei de Drogas).

E o envolvimento de adolescente no crime está explicitamente narrado na denúncia, não havendo prejuízo ao acusado – que se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação feita pelo Ministério Público.

Aliás:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DO RÉU GABRIEL – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – DECURSO DE MAIS DE 02 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA E A DATA DESTE JULGAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO DO CORRÉU – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Com relação à imputação do delito de corrupção de menores, existindo causa de aumento específica pelo envolvimento de criança ou adolescente no delito de tráfico, e sendo esta mais benéfica para o réu, impossível a incidência do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. Hipótese de emendatio libelli. Extinção, de ofício, da punibilidade do réu Gabriel, pela ocorrência da prescrição. Recurso da Defesa do réu Sérgio parcialmente provido, para, por emendatio libelli, afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores e reconhecer a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, redimensionando as penas privativa de liberdade do réu com relação ao crime de tráfico. (TJSP, Apelação Criminal n.º 0001970-74.2016.8.26.0616, 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda, julgado em 14/08/2020) Apelação – Tráfico de entorpecentes, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores – Recurso da defesa – Absolvição por insuficiência de provas – Materialidade e autoria do crime de tráfico demonstradas – Apreensão de drogas e dinheiro em poder da acusada – Negativa da ré isolada nos autos – Depoimentos dos agentes da lei que participaram das diligências – Provas seguras – Condenação de rigor – Associação para o tráfico – Absolvição – Procedência – Inexistência de elementos concretos a comprovar o 'animus' associativo entre a ré e o adolescente – Hipótese que se coaduna mais com o mero concurso de agentes – Desclassificação do crime previsto no artigo 244-B, da Lei Federal 8069/90 para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, com reflexos na dosimetria-Princípio da especialidade. Dosimetria-Pena-base corretamente fixada no mínimo legal- Reincidência reconhecida na segunda fase – Aumento de 1/6, na terceira fase, em razão da causa de aumento- Aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei Federal 11343/06 – Não cabimento – Requisitos legais não preenchidos – Regime inicial fechado – Manutenção – Substituição penal incabível – Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal n.º 1500045-59.2019.8.26.0552, 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator José Vitor Teixeira de Freitas, julgado em 27/04/2021) Assim, passo a analisar os fatos descritos na denúncia na forma do art. 33, caput, combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Feita essa observação, à matéria de fundo.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

Observe-se.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 12-13, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse do acusado, bem como a quantia de R\$ 155,00 em dinheiro.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 66-68), sendo que o resultado foi positivo para “maconha”, “crack” e “cocaína”, drogas de uso proscrito no Brasil.

A autoria também é inconteste.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

A confissão, aliás, restou corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Deveras, os guardas civis municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na

denúncia. Relatam que estavam em patrulhamento de rotina próximo a local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando uma senhora os parou e avisou que havia dois jovens de moletom vendendo drogas ali perto. Dirigiram-se até o local indicado e se depararam com o réu e o adolescente mexendo numa pochete e contando dinheiro. Abordaram-nos e, em posse do adolescente, havia drogas; em posse do réu, uma quantia em dinheiro.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos guardas civis municipais de incriminar injustamente o acusado. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos guardas, permitem presumir que as drogas apreendidas com o acusado se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No mais, restou configurada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06.

Com efeito, restou comprovado que o réu estava praticando o crime com um adolescente no momento da abordagem que, segundo os depoimentos das testemunhas, figurava como traficante junto com ele.

O acusado, em seu interrogatório prestado em juízo sob o crivo do contraditório, confessou que havia sido convidado pelo adolescente para traficar no local.

Assim, o adolescente estava envolvido no delito, o que caracteriza a majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual "As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente (...)".

Sublinho, em atenção à tese levantada pela defesa, que o C. STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 221 (REsp n.º 1.112.326/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 8/2/2012), que o delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) constitui crime formal, de tal sorte que, para a sua configuração, basta a simples participação de menor de 18 anos em infração penal praticada por agente imputável, sendo despendida prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

E em se tratando de envolvimento de menor, o entendimento do colegiado pode ser aplicado analogicamente à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06 - o que afasta a tese defensiva de que o fato de o menor já estar eventualmente inserido no tráfico afastaria a incidência da majorante pretendida pela acusação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - Para a configuração de referida causa de aumento, basta o envolvimento de adolescente no crime de tráfico, não sendo relevante o fato dele já estar corrompido ou não. RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AUMENTO DA PENAS-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS - ACOLHIMENTO - A grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e a natureza das substâncias justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Negado provimento ao recurso da defesa e provido o recurso do Ministério Público, para aumentar as penas, fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (TJSP, Apelação Criminal n.º 0080810-79.2018.8.26.0050, 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda, julgado em 05/03/2020)

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, atento aos recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, revejo posicionamento anterior e passo a não vislumbrar inconstitucionalidade na incidência deste privilégio.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao

revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação do privilégio ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena".

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, o acusado faz jus à aplicação da forma privilegiada do tráfico. Com efeito, o réu é primário, possui bons antecedentes (f. 102-103) e não há outros indícios de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Cabível, portanto, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei n.º

11.343/06, uma vez que, com vontade e consciência, previamente ajustado e com unidade de desígnios com um adolescente, trazia consigo as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente,

portanto, a culpabilidade.

A par disso, tem-se que o acusado não tem maus antecedentes, bem como não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, o que atrai a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes (f. 102-103).

Por outro lado, importante ressaltar que, em seu interrogatório, o denunciado

afirmou ser usuário de drogas e consumi-las com frequência. Tal circunstância é desfavorável à sua conduta social, já que, além de traficar drogas, financia indiretamente esse delito equiparado a hediondo, crime esse que vem, cada vez mais, corroendo famílias e a própria sociedade.

Além disso, as circunstâncias do delito também são desfavoráveis. Com efeito, o denunciado estava na posse de entorpecentes de naturezas diversas, maconha, cocaína e crack, essa última de altíssimo poder destrutivo. Outrossim, a quantidade dos entorpecentes apreendidos foi significativa (f. 66-68 e 21-23).

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais preponderantes negativas (conduta social e circunstâncias do crime), fixo a pena base em 08 anos e 04 meses de reclusão – e 833 dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante da menoridade relativa para ser considerada, nos termos do art. 65, I, do CP, tendo em vista que o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (f. 05).

Incide, outrossim, a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que o acusado confessou em juízo a prática do delito.

Assim, reduzo a reprimenda em 1/3 (sendo 1/6 para cada atenuante), fixando-a, provisoriamente, em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão – e 555 dias-multa.

Por fim, na última fase, incide inicialmente a privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não ficou demonstrada sua dedicação a atividades criminosas, tampouco sua integração em organização criminosa.

No ponto, como a quantidade das drogas encontradas em seu poder foi sopesada na primeira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem e à míngua de outros critérios específicos, tem-se que a pena deve ser reduzida em 2/3, de modo a ser dimensionada em 01 ano, 10 meses e 06 dias de reclusão – e 185 dias-multa.

Na sequência, incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que o crime foi praticado com o envolvimento de adolescente.

No caso, como o adolescente tinha 15 anos de idade (f. 04) e estava em contato direto com as drogas, pois as estava traficando junto com o réu, tem-se que a intensidade de seu envolvimento impõe o aumento da pena em 1/3.

Desse modo, exaspero a reprimenda em 1/3, fixando-a, agora definitivamente, em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão – e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Considerando o quantum da reprimenda fixada e o fato de o delito de tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado, apesar de grave, não ser crime equiparado a hediondo (Tema Repetitivo n.º 600 do STJ), fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Presentes os requisitos legais, e sendo a medida adequada e socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem aplicadas pelo juízo da execução, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social no valor de três salários mínimos federais, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas apreendida, necessitando de resposta mais enérgica da Justiça Pública.

Em atenção à redação do art. 44, caput, da Lei n.º 11.343/06, ressalto que o STF, no Tema de Repercussão Geral n.º 626, permitiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, fixando a seguinte tese: “É inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006”.

Tendo em vista o desfecho da demanda, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que não mais subsistem os pressupostos da prisão preventiva, de modo que o réu poderá recorrer em liberdade,

se por outro motivo não estiver preso.

A demanda é apenas parcialmente procedente em razão da concessão do privilégio. Em razão do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu THIAGO DE SOUZA SANTOS, já qualificado, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão – e ao pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput e § 4.º, combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A pena privativa de liberdade aplicada fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social no valor de 3 salários mínimos federais vigentes nesta data. O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, “a”), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhadas do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA